

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة، يوم الأربعاء ٢٦ مارس ٢٠١٤م، الموافق ٢٥ جمادى الأولى ١٤٣٥هـ،
برئاسة معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، وسلمان عيسى سيادي،
والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، ونوفل بن عبدالسلام غريال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن
الحايكي، أعضاء المحكمة.

وبحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٢٠١٣/٢) لسنة (١١) قضائية .

المقامة من :

نجيب سلمان أحمد كيكسو .

وكيلته المحامية لولوة العوضي .

ضد :

١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

ويمثله جهاز قضايا الدولة .

٢- بنك البحرين والكويت .

وكيله المحامي راشد عبدالرحمن .

الإجراءات :

بتاريخ الثامن عشر من شهر يونيو لعام ٢٠١٣ م ، قام المدعي بإيداع صحيفة هذه الدعوى ،
الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ، طالباً الحكم :

أولاً : وبصفة أصلية ، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٨١) من قانون التجارة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٧ م ، والمُعدّلة بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٢ م .

ثانياً : وبصفة احتياطية ، الحكم بعدم دستورية نص المادة (٨١) من قانون التجارة ، المطعون عليها
فيما تضمنه من جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ومن جواز تجاوز الفائدة مبلغ الدين،
إذا جاوزت مدة السداد سبع سنوات .

قدّم مُمثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم :

أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون .
واحتياطياً : برفض الدعوى .

كما قدّم المدعى عليه الثاني مذكرة بدفاعه ، انتهى فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى .

ونُظِرَت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقَرَرَت المحكمة إصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المدعى عليه الثاني ، كان قد تقدم بطلب استصدار أمر أداء من قاضي المحكمة الكبرى برقم ٣/٤٢٥١/٢٠٠٨/٠٢ ، بإلزام المدعي بأن يؤدي إليه مبلغاً وقدره ١٦٤,٨٧٨/٩٧٨ ديناراً بحرينياً والفائدة الاتفاقية بواقع ٧,٢٥٪ من تاريخ رفع أمر الأداء حتى السداد التام ، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه في الدعوى المذكورة قد حصل على قرض من البنك ، على أن يقوم بسداده على أقساط ، وقد تقاعس عن السداد ، فترصد في ذمته المبلغ المطالب به ، والذي رفض سداده ، على الرغم من تكليفه بذلك ، وإذ تم رفض طلب أمر الأداء ، فقد تحدد جلسة لنظر الموضوع أمام المحكمة الكبرى المدنية الخامسة ، وتداولت الدعوى أمامها ، وطلب المدعى عليه رفض الدعوى على سند من قيام البنك باحتساب فوائد تأخيرية تراكمية خلافاً لاتفاقية القرض لسنة ٢٠٠٣م ، مما ترتب عليه استغراق هذه الفوائد لأصل الدين ، كما طالب التصريح له بإقامة الدعوى الدستورية لمخالفة حكم المادة (١/٨١) من قانون التجارة للمادة الثانية من الدستور . وقضت المحكمة بنسب خبير للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق الحكم ، وقد انتهى الخبير - بعد بحث أوجه اعتراضات طرفي الدعوى - إلى أحقية البنك في مبلغ مقداره ١٥٧,٣١٤/٨٨٢ ديناراً بحرينياً .

وبجلسة ٢١ فبراير ٢٠١١م ، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى البنك المدعي ، المبلغ الذي انتهى إليه الخبير ، والفائدة التأخيرية بواقع ٢٪ سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، والمصاريف .

وإذ لم يرتض كل من البنك المدعي ، والمدعى عليه في الدعوى الموضوعية هذا الحكم ، فقد أقام الأول ، الاستئناف رقم ٢٠١١/٩٥٧ ، أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة ، بطلب الحكم بتعديل الفائدة المقضي بها لتكون ٧,٢٥ ٪ ، وأقام الثاني الاستئناف رقم ٢٠١١/١٠٢٥ بطلب الحكم ، وقبل الفصل في الموضوع بوقف الاستئناف ، والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برفض الدعوى .

وبعد ضم الاستئنافين لنظرهما معاً ، تقدم المدعي بجلسة ١٦ أكتوبر ٢٠١١ م ، بمذكرة طلب فيها قبل الفصل في الدعوى ، التصريح له برفع الدعوى الدستورية ، طعنًا على نص المادة (٨١) فقرة (١) من المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٧ م ، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٢ م ، ولقد تمسك المدعي بهذا الدفع في أكثر من مذكرة لاحقة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، فقررت بجلسة ٢٧ مايو ٢٠١٣ م ، إمهال المدعي شهرًا لإقامة الدعوى بعدم دستورية نص المادة (٨١) من قانون التجارة ، فأقام دعواه المائلة بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠١٣ م .

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى ، لعدم اتصال هذه المحكمة بها بالطريق الذي رسمه القانون ، على سند من أن محكمة الموضوع لم تبحث جدية الدفع ، بتحديد المواد المطعون بعدم دستورتها ، وأوجه عدم الدستورية ، واكتفت فقط بالتصريح للطاعن بإقامة دعواه ، فهذا الدفع مردود ، ذلك أنه ووفقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ م ، بإنشاء المحكمة الدستورية ، فإنه يتضح أن المشرع لم يلزم محكمة الموضوع بالإفصاح صراحة عن أوجه تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية ، ولا ذكر النصوص المدفوع بعدم دستورتها ، طالما يمكن استخلاصها واستنتاجها من قرار المحكمة .

لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على أوراق الدعوى الموضوعية ، ومن مذكرات المستأنف في الاستئناف رقم ٢٥/١٠١١/٢٠١١ أنه ضمّنها دفعًا بعدم دستورية الفقرة (١) من المادة (٨١) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٧م ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٢م ، وبعد بحث جدية هذا الدفع من محكمة الموضوع ، صرّحت لمبديه برفع دعوى بعدم دستوريته ، وذلك كله يكشف بذاته عن أن محكمة الموضوع جالت ببصرها في هذا الدفع قبل التصريح للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية ، مما يقطع بتقديرها جديته ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله ، وإردًا على غير سند ، متعين الرفض .

وحيث إنه لما كان قضاء المحكمة الدستورية قد استقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية ذا أثر في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة في دعوى الموضوع ، وبالقدر اللازم والضروري للفصل فيها ، من دون زيادة أو نقصان .

متى كان ذلك وكان الثابت أن البنك المدعى عليه الثاني في الدعوى الماثلة ، قد أقام الدعوى الموضوعية بطلب الحكم بإلزام المدعي في الدعوى الماثلة ، بأن يؤدي إليه المبلغ المدين به والفائدة الاتفاقية بواقع ٧,٢٥٪ من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام ، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى البنك المدعي المبلغ المقضي به والفائدة التأخيرية بواقع ٢٪ سنويًا من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ، فطعن البنك في هذا الحكم طالبيًا تعديل الحكم المستأنف ، والحكم بإلزام المستأنف ضده بدفع فائدة قدرها ٧,٢٥٪ عن المبلغ المقضي به ، كما طعن المدعى عليه في الحكم المشار إليه بالاستئناف طالبيًا إلغائه ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى . وأثناء نظر هذين الاستئنافين دفع المستأنف الأخير بعدم دستورية الفقرة (١) من المادة (٨١) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٧م ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٢م ، والتي جرى نصها على أنه : « تستحق الفوائد عن

التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك^(٨) ، لمخالفتها للمادة الثانية من الدستور ، توصلاً إلى عدم استحقاق البنك للفوائد عن التأخير في الوفاء بأقساط القرض ، والتي تضمنها المبلغ المُقضي به كأحد طلبات المستأنف في استئنائه المُشار إليه سلفاً ، مما يؤثر في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع ، وبالتالي تتوافر له مصلحة شخصية ، ومباشرة في الدعوى الدستورية الراهنة .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المُشرّع للخصوم مباشرتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المُثار أمام محكمة الموضوع ، وفي الحدود التي تقدر فيها جديته .

ولما كان الثابت من مذكرات المستأنف في الاستئناف رقم ٢٠١١/١٠٢٥ أنه قصر دفعه بعدم الدستورية على نص الفقرة الأولى من المادة (٨١) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٧م ، المُعدل بالمرسوم بقانون رقم (٤) لسنة ١٩٩٢م ، ولم يتعداه إلى غيره من باقي فقرات المادة (٨١) المُشار إليها ، مما يتعين معه حصر نطاق الدعوى الماثلة في نص الفقرة الأولى من المادة (٨١) دون غيرها من باقي فقرات المادة (٨١) المُشار إليها ، والتي لم يتناولها المدعي في دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع ، إذ لا تملك من تلقاء نفسها ، التصريح للمدعي برفع الدعوى الدستورية فيما يجاوز الدفع المبدى منه ، مما يضحى معه تبعاً لذلك أن الطعن بصفة احتياطية بعدم دستورية المادة (٨١) في مجمل فقراتها طعن لا يصادف القبول .

ولما كانت مناعي المدعي على نص الفقرة الأولى من المادة (٨١) من قانون التجارة ، مخالفتها للمادة الثانية من الدستور المعدل ، وذلك انطلاقاً من القول بأن فوائد التأخير المستحقة تعد من الربا المحرم شرعاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية من الدستور في حكم المصدر الرئيسي للتشريع ، وفي مصاف القواعد القانونية الوضعية التي من شأنها نسخ ما كان سابقاً عليها متعارضاً معها من نصوص التشريعات الوضعية نسخاً ضمنياً إذ صارت بذاتها واجبة الأعمال من دون حاجة إلى صدور تشريع يقننها .

وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٨١) من قانون التجارة (المطعون عليها) تنص على أن :
« تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية ، بمجرد استحقاقها ، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك » . وقد نص دستور مملكة البحرين ، المعدل الصادر في سنة ٢٠٠٢م ، في المادة الثانية منه على أن : « الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع » .

وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح - المنوطة بالمحكمة الدستورية - تستهدف أصلاً صون الدستور وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه . وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور في مختلف نصوصه من ضوابط وقيود ومن ثم فإنه يتعين عند الفصل فيما يثار في شأن التشريعات من مطاعن تستهدف نقض قرينة الدستورية ، استظهار هذه الضوابط والقيود وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة تلك التشريعات لها .

وحيث إن المذكرة التفسيرية للدستور - والتي يعتبر ما ورد فيها مرجعاً لتفسير أحكامه وفقاً لما أشارت إليه مقدمة الدستور - جاء فيها « ... ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدراً رئيسياً للتشريع ، وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية أساسية ، من دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها ، أو يكون من المستحسن

تطوير الأحكام في شأنها بما لا يخالفها ، مسايرة لضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن ^(١) . ذلك أن تقنين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن مألوفة ، أو معروفة ، وكذلك ما جدّ في عالمنا المعاصر وما يقتضيه الوجود في المجتمع الدولي من صلات وعلاقات ومعاملات كل ذلك يستأهل الروية ويتطلب جهوداً . وحتى لا يقع المشرّع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهّل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وخاصة في مثل نظم الشركات والتأمين والبنوك والقروض وما إليها ، كما يلاحظ بهذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور وقد قرر أن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) إنما يحمل المشرّع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسّع ذلك إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو آجلاً بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرّع ذلك .

ولما كان مفاد ما تقدم أن نص المادة الثانية من الدستور المعدل ، وفي ضوء تفسيرها الدستوري ، هو توجيهه للمشرّع للأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسّع ذلك ، باعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر موضوعي يستلهم منه المشرّع القواعد القانونية التي يضعها فيما يعرض له من أمور ، وصياغة نص المادة الثانية من الدستور تُفيد بأنها تجعل من الشريعة الإسلامية مصدراً مادياً بين المصادر الأخرى للتشريع ، ومن ثم فليس من شأن النص الدستوري المدعى مخالفته ، أن يلزم المشرّع العادي بأن يقتصر فيما يستقيّه من قواعد التشريع على الشريعة الإسلامية وحدها ، بما لا يكون هناك ثمة ما يمنعه من استمداد تلك القواعد من مصادر أخرى يراها ملائمة لمقتضى الحال ، من دون أن يقع بذلك في موقع المخالفة الدستورية .

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، ولما كان مبنى الطعن مخالفة نص الفقرة الأولى من المادة (٨١) من قانون التجارة ، للمادة الثانية من الدستور . وإذ كان النص الدستوري - وعلى ما سلف بيانه - لا يمنع من قيام المشرع بالأخذ بقواعد التشريع من مصادر أخرى ، ومن ثم فإن النعي بمخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة (٨١) من قانون التجارة لنص المادة الثانية من الدستور المعدل ، وأياً كان وجه الرأي فيه من الناحية الفقهية الإسلامية ، فإنه نعي غير سديد الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوى .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة ، برفض الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات ، ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة